

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 247.331 van 17 maart 2020
in de zaak A. 230.288/XII-8870**

In zake:

1. de NV JAN DE NUL
 2. de NV TDP
 3. COMM. VA TINC
 4. de NV ABETEC ARCHITECTEN & INGENIEURS
 5. de BV ARCHITECTENBUREAU BART DEHAENE BV
 6. de CV SILEGHEM & PARTNERS, ARCHITECTEN EN INGENIEURS
 7. de CV ARCHIPL ARCHITECTEN
 8. de BV DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
 9. de BV TRIAS ARCHITECTEN BV
- bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Joost Bosquet
kantoor houdend te 2650 Edegem
Mechelsesteenweg 326
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET
ONDERWIJS (AGION)
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Annelies Verlinden en Evelien De Raeymaecker
kantoor houdend te 1050 Brussel
Louizalaan 106
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 20 februari 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[d]e beslissing van de Afgevaardigd bestuurder van AGION waarbij de aanvraag tot deelneming van verzoekende partijen in het kader van de overheidsopdracht ‘DBFM-project Pro-jectcluster Provinciaal der Broeders van Liefde-KaSORT; dossiernummer DBFM_PSP-CL02’ niet wordt geselecteerd.”

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 maart 2020, om 11.00 uur.

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Joost Bosquet, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaten Annelies Verlinden, Evelien De Raeymaecker en Maithé Bultheel, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (hierna: AGION) schrijft een opdracht voor werken uit voor een DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) project “Projectcluster Provinciaal der Broeders van Liefde – KaSORT”.

Deze projectcluster omvat als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016 ‘betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten’, het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) van 4 scholenbouwprojecten te Zwijnaarde, Tessenderlo, Turnhout en Zelzate. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de

DBFM-overeenkomst per scholenbouwproject maken het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure van deze cluster.

AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt aangekondigd als een mededingingsprocedure met onderhandeling in de zin van art. 2, 24°, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’.

De opdracht wordt geraamd op 82 miljoen euro (BTW niet inbegrepen).

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 23 april 2019 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie op 24 april 2019.

3.3. De selectieleidraad bevat onder punt 2.14 bepalingen met betrekking tot de uitsluiting van kandidaten, en onder punt 2.20.5 bepalingen met betrekking tot de vereisten inzake het indienen van een aanvraag tot deelneming. Onder punt 3.2 wordt bepaald dat indien de aanvraag tot deelneming wordt ingediend door een samenwerkingsverband deze door alle leden van het samenwerkingsverband dient te worden ondertekend.

3.4. De verzoekende partijen hebben tijdig een aanvraag tot deelneming ingediend.

3.5. Met een e-mailbericht van 27 september 2019 vraagt de verwerende partij bijkomende informatie aan de verzoekende partijen aangaande de vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheid van verscheidene leden van het samenwerkingsverband.

3.6. Met een e-mailbericht van 11 oktober 2019 bezorgen de verzoekende partijen de gevraagde stukken waaruit volgens hen de ondertekeningbevoegdheid blijkt.

Betreffende de elektronische ondertekening door Eric Van Damme in plaats van Frédéric Van Damme vermelden de verzoekende partijen:

“Wij verwijzen hiervoor naar de verklaring op eer van de heren Eric en Frédéric Van Damme die u terugvindt als BIJLAGE 9a. Bij de ondertekening door dhr. Frédéric Van Damme waren er problemen met de registratie van de handtekening van de heer Frédéric Van Damme. Om een door de overheid niet verklaarbare reden stond Frédéric op het ogenblik van de indiening van de aanvraag verkeerdelijk geregistreerd als ambtenaar, terwijl hij nooit ambtenaar is geweest. Ondanks herhaaldelijk telefonisch contact met de mensen van e-tendering slaagden deze er niet in om het euvel tijdig recht te zetten. Om die reden heeft de heer Eric Van Damme, die eveneens beschikt over de bevoegdheid om te mogen ondertekenen, in naam van Frédéric Van Damme getekend. Wij voegen eenvoudigheidshalve hier ook BIJLAGE 9b en 9c toe, die reeds in onze submittie zitten.

- de publicatie in het Belgisch Staatsblad d.d. 06/12/2016 van de benoeming tot bestuurders door de algemene vergadering d.d. 11/06/2016 tot de algemene vergadering van 2022 van de heren Eric en Frédéric Van Damme alsook de benoeming van dhr. Eric Van Damme tot gedelegeerd bestuurder met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid;

- de gecoördineerde statuten d.d. 15/07/2014 met verwijzing naar artikel 31. Bestuursbevoegdheden; Voor de volledigheid voegen wij de bijzondere volmachten met terugwerkende kracht toe van ABETEC architecten & ingenieurs, TriAS architecten en Dierendonckblancke Architecten aan de heer Eric Van Damme (BIJLAGE 10).”

3.7. Op 4 februari 2020 beslist de verwerende partij om de verzoekende partijen uit te sluiten van verdere deelname aan de plaatsingsprocedure op grond van de volgende motivering:

“

4. Beoordeling van de Aanvragen tot Deelneming

4.7 **Aanvraag tot Deelneming van consortium Jan De Nul NV – TDP NV – Tinc Comm. VA - ABETEC architecten & ingenieurs NV – Architectenbureau Bart Dehaene BV BVBA – Sileghem & Partners, Architecten en Ingenieurs CVBA – Archipl Architecten CVBA – Dierendonckblancke Architecten BVBA – TriAS architecten BV BVBA (“Jan De Nul – PPBL”)**

4.7.1 *Volledigheid en formele regelmatigheid*

In het kader van het nazicht van de formele regelmatigheid werd in eerste instantie een anomalie vastgesteld in de ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming met betrekking tot drie leden van de Kandidaat, ABETEC architecten & ingenieurs, Dierendonckblancke Architecten en TriAS architecten. Immers werd namens deze leden van de Kandidaat een bijzondere volmacht gevoegd op grond waarvan Frédéric Van Damme werd gevolmachtigd de Aanvraag tot Deelneming te ondertekenen, terwijl de Aanvraag tot Deelneming elektronisch ondertekend werd door Eric Van Damme en Kristien De Vries.

In het licht van deze vaststelling werd aan deze Kandidaat bijkomende informatie gevraagd met betrekking tot de vastgestelde anomalie.

De Kandidaat bezorgde de bijkomende informatie tijdig. Concreet werd respectievelijk namens ABETEC architecten & ingenieurs, Dierendonckblancke Architecten en TriAS architecten afzonderlijk een bijzondere volmacht die met terugwerkende kracht werd verleend, gevoegd. Namens ABETEC architecten & ingenieurs werden eveneens de gecoördineerde statuten, het besluit van de Algemene Vergadering van 11 juni 2016 houdende de benoeming van Eric Van Damme als gedelegeerd bestuurder van ABETEC architecten & ingenieurs alsook een verklaring op eer gevoegd. In deze verklaring op eer, alsook in het begeleidend schrijven van de Kandidaat bij de aanvullende informatie, werd gemeld dat er bij de elektronische ondertekening door Frédéric Van Damme problemen zouden zijn gerezen met de registratie van de handtekening van Frédéric Van Damme. Om een niet verklaarbare reden zou Frédéric Van Damme op het ogenblik van de indiening van de Aanvraag tot Deelneming verkeerdelijk geregistreerd zijn als ambtenaar (hetgeen niet correct zou zijn). De Kandidaat zou herhaald telefonisch contact met de helpdesk van het platform e-tendering, doch slaagde er niet in aan het probleem te verhelpen. Om die reden zou Eric Van Damme de Aanvraag tot Deelneming “in naam van Frédéric Van Damme” hebben ondertekend.

Op basis van de toelichtende informatie blijkt vooreerst dat de heer Eric Van Damme op het moment van de ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming gedelegeerd bestuurder was van ABETEC architecten & ingenieurs en overeenkomstig artikel 32 van de gecoördineerde statuten derhalve alleen handelend ABETEC architecten & ingenieurs rechtsgeldig mag vertegenwoordigen en namens ABETEC architecten & ingenieurs de Aanvraag tot Deelneming alleen mocht ondertekenen (niettegenstaande de bijzondere volmacht gegeven aan Frédéric Van Damme).

Daarnaast nam de Aanbestedende Overheid in het licht van de verkregen informatie contact op met de helpdesk van het e-tendering platform teneinde te achterhalen of op het moment van indiening van de Aanvraag tot Deelneming enige (technische) anomalieën bestonden die de elektronische ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming van de Kandidaat door Frédéric Van Damme effectief belemmerden. De helpdesk van het e-tendering platform bevestigde vooreerst dat er op het moment van het indienen van de Aanvraag tot Deelneming geen technische problemen c.q. anomalieën werden vastgesteld die de ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming onmogelijk maakten. Eveneens verduidelijkte de helpdesk dat Frédéric Van Damme *ook* (en derhalve niet uitsluitend) als “openbare aankoper” was geregistreerd en zich op het moment van indiening mogelijk enkel in die hoedanigheid van “openbare aankoper” zou hebben aangemeld. Om weliswaar rechtsgeldig de Aanvraag tot Deelneming namens een onderneming te ondertekenen, dient de ondertekenaar in kwestie zich aan te melden in de hoedanigheid van (vertegenwoordiger van een) onderneming. De beweerde (technische) anomalieën kunnen derhalve

niet te wijten zijn aan het e-tendering platform en de toelichting van de Kandidaat kan niet worden aanvaard.

Dit geldt des te meer nu kan worden vastgesteld dat de Kandidaat noch voor, noch op het moment van indiening van de Aanvraag tot Deelneming enige opmerking formuleerde met betrekking tot de beweerde onmogelijkheid tot ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming ten aanzien van de Aanbestedende Overheid, doch slechts nadat de Kandidaat werd verzocht in dit verband bijkomende informatie te verstrekken.

Voorts diende de ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming namens Dierendonckblancke Architecten en TriAS architecten door Eric Van Damme nader te worden geanalyseerd op basis van de *a posteriori* gevoegde bijzondere volmachten die met terugwerkende kracht werden verleend. Weliswaar geldt dat bijzondere volmachten die na de ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming worden verleend met terugwerkende kracht niet kunnen worden aanvaard. Dit wordt ook bevestigd in de vaste rechtspraak van de Raad van State waarin de Raad stelt dat een volmacht tot ondertekening niet *post factum* en buiten de indieningstermijn mag worden gegeven omdat er dan geen enkele verbintenis van de inschrijver voorhanden is op het moment van indiening. Hieruit volgt dat de *a posteriori* gevoegde bijzondere volmachten met terugwerkende kracht niet kunnen worden aanvaard teneinde de niet-rechtsgeldige ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming alsnog te verantwoorden c.q. te dekken.

In het licht van het voorgaande stelt de Aanbestedende Overheid vast dat de handtekenbevoegdheid voor twee leden van de Kandidaat, Dierendonckblancke Architecten en TriAS architecten niet voldoende werd aangetoond en dat de Aanvraag tot Deelneming namens deze twee leden van de Kandidaat niet door de daartoe bevoegde persoon rechtsgeldig elektronisch werd ondertekend.

Wat betreft de gevolgen van de niet-rechtsgeldige ondertekening van de Aanvraag tot Deelneming namens Dierendonckblancke Architecten en TriAS architecten door Eric Van Damme verwijst de Aanbestedende Overheid naar artikel 2.20.5 van de Selectieleidraad dat uitdrukkelijk stipuleert dat de Kandidaat erop wordt gewezen dat zijn Aanvraag tot Deelneming, overgelegd via e-tendering elektronisch dient te worden ondertekend, *in voorkomend geval door alle leden van het Samenwerkingsverband*, met een geldig gekwalificeerde elektronische handtekening. In dezelfde zin bepaalt artikel 44, §1 (j^o artikel 43) KB Plaatsing dat de verplichting tot ondertekening van de offerte door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden eveneens uitdrukkelijk van toepassing is op elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers wanneer de offerte wordt neergelegd door een dergelijke combinatie. Deze bepaling dient, mede in het licht van artikel 2.20.5 van de Selectieleidraad, naar analogie te worden toegepast op de ondertekening van de Aanvragen tot Deelneming. Elke deelnemer aan de combinatie dient zich immers uitdrukkelijk en afzonderlijk te verbinden tot de inschrijving. De niet-naleving van voorschriften met betrekking tot de elektronische ondertekening leidt tot de substantiële onregelmatigheid van de Aanvraag tot Deelneming. Deze zienswijze wordt eveneens bevestigd in de rechtspraak van de Raad van State die stelt dat de niet-rechtsgeldige ondertekening door niet alle deelnemers aan de combinatie een substantiële tekortkoming vormt die niet kan worden gedekt. Deze rechtspraak dient *in casu*, gelet op artikel 2.20.5. van de Selectieleidraad, eveneens naar analogie te worden toegepast.

Gelet op voormelde substantiële onregelmatigheid wordt de Aanvraag tot Deelneming als onvolledig en formeel niet regelmatig beoordeeld.

4.7.2 Conclusie

De Aanvraag tot Deelneming van de Kandidaat wordt als niet volledig en formeel regelmatig beoordeeld. De Kandidaat wordt uitgesloten van het verder verloop van de plaatsingsprocedure.

”.

3.8. Met een aangetekend schrijven en e-mailbericht van 5 februari 2020 worden de verzoekende partijen door de verwerende partij ervan in kennis gesteld dat “de aanvraag tot deelneming van het consortium (...) niet wordt geselecteerd”.

IV. Schorsingsvoorwaarden

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

V. Onderzoek van het enig middel

Uiteenzetting van het middel

5. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 42, § 2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing

2017), van de materiële-motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet het buiten toepassing laten van art. 2.20.5 van de selectieleidraad, de ontstentenis van de rechtens vereiste feitelijke en juridische grondslag,

“Doordat, de bestreden beslissing verzoekende partij van de verdere deelname aan de mededingingsprocedure met onderhandeling uitsluit met verwijzing naar een zogenaamde substantiële onregelmatigheid van diens aanvraag tot deelneming, omwille van het ontbreken - minstens het onvolmaakt zijn - van de volgens de selectieleidraad vereiste geavanceerde elektronische handtekeningen van alle leden van het samenwerkingsverband, waarbij deze handtekeningen op dat ogenblik van ondertekening zogenaamd via een niet retroactief geldig mandaat of statutaire handtekeningsclausule afgedekt dienden te zijn.

Terwijl, overeenkomstig art. 42 §2 KB Plaatsing in het kader van een mededingingsprocedure met onderhandeling de individuele handtekening van de kandidaat, wat betreft de aanvraag tot deelneming niet vereist is en alleen de indieningsrapporten die betrekking hebben op de initiële offerte en de definitieve offerte ondertekend dienen te zijn bij wijze van vormvereiste;

Terwijl, het binnen een gunningsprocedure niet door een daartoe tijdig bevoegd / gemandateerd persoon ondertekenen van stukken gelijk wordt gesteld met het niet ondertekenen van deze stukken in de zin van art. 42 §2 K.B. Plaatsing;

Terwijl, overeenkomstig art. 43-44 KB Plaatsing de handtekeningen van het in art. 42 KB Plaatsing bedoelde indieningsrapport dienen te zijn geplaatst door de personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te binden, hetgeen veronderstelt dat het nazicht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid pas aan de orde is van zodra de aanvragen tot deelneming in de eerste plaats ondertekend dienen te zijn bij wijze van vormvereiste, quod non;

Terwijl, de toepassing van art. 42, 43, §1, 44 en 76 K.B. Plaatsing ertoe leidt dat het ontbreken van een handtekening of een door een geldige vertegenwoordiging gedekte handtekening op een aanvraag tot deelneming een volslagen andere draagwijdte heeft dan de ondertekening van een offerte, gelet op verschillende finaliteit van beide documenten en het uitdrukkelijk keuzerecht tot ondertekening van aanvragen tot deelneming neergelegd in art. 42 §2 K.B. Plaatsing.

Terwijl, de toepassing van voormelde bepalingen van het K.B. Plaatsing geen reglementaire verplichting inhoudt tot ondertekening van aanvragen tot deelneming door een daartoe tijdig bevoegd persoon, laat staan het gebrek aan deze ondertekening van aanvragen tot deelneming of daarmee gelijk gestelde gevallen aan de sanctie van nietigheid of substantiële onregelmatigheid onderwerpt.

Terwijl, de materiële motiveringsplicht ertoe strekt dat de bestuurlijke besluitvorming teruggaat op een zorgvuldige feitenvinding die aanleiding

geeft tot rechtens en in feite draagkrachtige motieven die in redelijkheid de niet-sectie kunnen verantwoorden;

Terwijl, het zonder meer transponeren van het leerstuk van de niet ondertekening der offertes op de niet ondertekening van een aanvraag tot deelneming - bij het gebrek aan nietigheidssanctie voorzien in de reglementering of in de selectieleidraad - leidt tot een gebrek aan draagkrachtige juridische motieven om de kandidatuur als ‘substantieel onregelmatig’ te kwalificeren, en dus een gebrek in de materiële motiveringsplicht;

Terwijl, met toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur de aanbestedende overheid bij de beoordeling van de aanvragen tot deelneming steeds rekening dient te houden met alle relevante elementen, waaronder de verschillende finaliteit van aanvragen tot deelneming en offertes;

Zodat, de bestreden beslissing die de aanvraag tot deelneming van verzoekende partij als substantieel onregelmatig heeft geweerd, zonder daartoe in concreto draagkrachtige motieven na een zorgvuldige feitenvinding te hanteren, en daarbij het cruciale onderscheid tussen offerten en aanvragen tot deelneming uit het oog verliest, de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen en beginselen schendt.”

In de toelichting bij het middel betogen de verzoekende partijen met betrekking tot de gevraagde toepassing van artikel 159 van de Grondwet nog dat, voor zover de bestreden beslissing steunt op het voorschrijven van de ondertekeningsverplichting van de aanvraag tot deelneming in de selectieleidraad (art. 2.20.5 van deze leidraad), deze laatste bepaling ingaat tegen het door artikel 42, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 voorgeschreven facultatief karakter van de ondertekening van de aanvraag tot deelneming. De voormelde bepaling van de selectieleidraad dient dan ook met toepassing van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing te worden gelaten, zodat de bestreden beslissing niet op deze bepaling van de selectieleidraad kan steunen om de nietigheid van de aanvraag tot deelneming van de verzoekende partijen te ondersteunen.

Beoordeling

6. Uit de hiervoor onder randnummer 3.7. aangehaalde motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag tot deelneming van de verzoekende partijen als “niet volledig en formeel regelmatig [wordt] beoordeeld”, om welke reden de kandidaat “wordt uitgesloten van het verder verloop van de plaatsingsprocedure”.

7. De verzoekende partijen betwisten niet dat de aanvraag tot deelneming bij de indiening ervan niet geldig was ondertekend namens Dierendonckblanke Architecten en TriAS architecten. Evenmin betwisten zij de vaststelling door de verwerende partij in de bestreden beslissing, na een door de verwerende partij uitgevoerd onderzoek bij de helpdesk van het e-tendering platform, dat de beweerde (technische) anomalieën die de elektronische ondertekening van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat door Frédéric Van Damme belemmerden, niet te wijten zijn aan het e-tendering platform en de toelichting van de kandidaat hieromtrent niet kan worden aanvaard.

In het middel betwisten de verzoekende partijen op het eerste gezicht dan ook uitsluitend de gevolgen die aan de niet-rechtsgeldige ondertekening door deze leden van het samenwerkingsverband worden verbonden.

8. Artikel 42, § 2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’, waarvan de schending in dit middel wordt opgeworpen, bepaalt :

“§ 2. In het kader van een niet-openbare procedure, een mededingingsprocedure met onderhandeling, een concurrentiegerichte dialoog en een innovatiepartnerschap, is de individuele handtekening van de kandidaat, wat betreft de aanvraag tot deelneming, niet vereist. Dit is evenmin het geval, wanneer dit voorgelegd moet worden, voor het UEA. Beide voormelde documenten kunnen niettemin, op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, op een globale manier getekend worden op het indieningsrapport dat samen gaat met de aanvraag tot deelneming. Als de ondernemer van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, moet het UEA, wanneer dit voorgelegd moet worden, opnieuw worden bijgevoegd en globaal ondertekend naar aanleiding van het in het tweede lid bedoelde indieningsrapport.

Wanneer in een volgende fase offertes en hun bijlagen worden ingediend in één van de in het eerste lid bedoelde procedures, wordt evenmin een individuele handtekening vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet. Deze documenten worden op een globale manier getekend op het erbij horende indieningsrapport.

In het kader van de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap, moeten evenwel alleen de indieningsrapporten die betrekking hebben op de initiële offerte en de definitieve offerte ondertekend zijn.”

Deze bepaling wordt in het verslag aan de Koning toegelicht als volgt:

“Paragraaf 2 betreft de niet-openbare procedures, de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap. Het eerste lid zegt dat de aanvraag tot deelneming en het UEA niet afzonderlijk dienen getekend te worden. De ondernemer kan de documenten echter wel globaal ondertekenen via het indieningsrapport dat er betrekking op heeft. Het tweede lid van deze paragraaf voorziet dat de offertes en hun bijlagen globaal moeten ondertekend worden via het indieningsrapport.

Er dient genoteerd dat de ondertekening van het indieningsrapport bedoeld in het eerste lid van paragraaf 2 een onmiskenbaar voordeel biedt voor de ondernemer. Zelfs al is deze facultatief, dan nog laat het toe dat de ondernemer het UEA slechts éénmaal moet voorleggen. Immers, indien het eerste UEA niet getekend blijkt of niet geldig getekend blijkt via het indieningsrapport dat samengaat met de aanvraag tot deelneming, moet de ondernemer zijn UEA een tweede maal indienen samen met zijn offerte en haar bijlagen. Het UEA, de offerte en haar bijlagen vormen aldus het voorwerp van een nieuw indieningsrapport dat moet ondertekend worden. Het laatste lid van deze paragraaf is gewijd aan de mededingingsprocedure met onderhandeling en aan het innovatiepartnerschap. Voor deze procedures is voorzien dat niet alle aan een offerte gehechte indieningsrapporten dienen ondertekend te worden. Immers moeten enkel de indieningsrapporten betreffende de initiële en de finale offerte ondertekend te zijn. Dit lid geldt onverminderd de mogelijkheid voor de ondernemer om zijn aanvraag tot deelneming te ondertekenen overeenkomstig het eerste lid van paragraaf 2.”

9. De op de opdracht toepasselijke selectieleidraad bepaalt onder meer wat volgt:

“2.14 Uitsluiting van Kandidaten

Indien de Kandidaten handelen in strijd met de eisen gesteld in de Selectie- en de Gunningsfase, kan dit leiden tot onregelmatigheid van de door de Kandidaten in te dienen documenten en tot uitsluiting van de desbetreffende Kandidaten aan de (verdere) deelname aan deze Plaatsingsprocedure.

Indien een geselecteerde Kandidaat in een latere fase van de Plaatsingsprocedure niet meer voldoet aan één of meer van de Selectievoorwaarden, heeft de Aanbestedende Overheid (Clusterverantwoordelijke) het recht deze Kandidaat uit te sluiten (art. 60 van het K.B. van 18 april 2017).”

Inzake het indienen van een aanvraag tot deelneming bevat de selectieleidraad onder punt 2.20.5 de volgende vereisten:

“Aanvragen tot Deelneming
(...)”

Conform artikel 14 Overheidsopdrachtenwet moeten Aanvragen tot Deelneming elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite <https://eten.publicprocurement.be/>

De Kandidaat wordt erop gewezen dat zijn Aanvraag tot Deelneming, overgelegd via e-tendering, elektronisch moet worden ondertekend, in voorkomend geval door alle leden van het Samenwerkingsverband, met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De Kandidaat voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden: (gecoördineerde) statuten van de onderneming waarbij precies wordt aangeduid op basis van welk(e) artikel(en) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt, benoemingsbesluit(en) en/of volmacht(en).

Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: <http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten>. Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden verkregen op de website <http://www.publicprocurement.be> of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.

Aanvragen tot Deelneming die niet uiterlijk op het in de tweede paragraaf vermelde tijdstip zijn ontvangen, zijn onregelmatig en worden uitgesloten.”

Ook onder punt 3.2 van de selectieleidraad wordt bepaald dat indien de aanvraag tot deelneming wordt ingediend door een samenwerkingsverband de aanvraag tot deelneming door alle leden van het samenwerkingsverband dient te worden ondertekend.

10. Terecht lijken de verzoekende partijen er in hun verzoekschrift op te wijzen dat het feit dat een gebrek in de ondertekening van een aanvraag tot deelneming niet zonder meer kan worden gelijkgesteld met de ondertekening van een offerte nu de artikelen 42, 43, § 1, 44 en 76 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 geen reglementaire verplichting lijken in te houden tot geldige ondertekening van aanvragen tot deelneming. Artikel 42, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 bepaalt dat onder meer met betrekking tot een mededingingsprocedure met onderhandeling, de individuele handtekening van de kandidaat, wat betreft de aanvraag tot deelneming, niet is vereist, maar het voorziet tegelijkertijd in de mogelijkheid om onder meer de aanvraag tot deelneming op een globale manier te

tekenen op het indieningsrapport dat samen gaat met de aanvraag tot deelneming. *Prima facie* betreft het een mogelijkheid en dus geen verplichting.

11. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de beslissing om de verzoekende partijen uit te sluiten van het verdere verloop van de plaatsingsprocedure omwille van de niet-rechtsgeldige ondertekening van de aanvraag tot deelneming steunt op artikel 2.20.5 van de selectieleidraad. De verwerende partij lijkt daarbij op het eerste gezicht ook rekening gehouden te hebben met het onderscheid tussen de ondertekening van een offerte en van een aanvraag tot deelneming nu er in de bestreden beslissing slechts sprake is van een toepassing naar analogie van de in artikel 44, § 1, vervatte regel dat de verplichting tot ondertekening van de offerte door een bevoegde persoon ook van toepassing is op elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers.

12. Anders dan de verzoekende partijen dit zien, lijken de voormelde bepalingen van het koninklijk besluit plaatsing 2017 niet uit te sluiten dat een aanbestedende overheid, zoals de verwerende partij in onderhavig geval gedaan blijkt te hebben, in de selectieleidraad alsnog een verplichting opneemt tot ondertekening van de aanvraag tot deelneming met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening conform artikel 44 van het koninklijk besluit plaatsing 2017.

Daarbij wordt ook vastgesteld dat de verzoekende partijen geen opmerkingen blijken te hebben gemaakt over de wettigheid van artikel 2.20.5 van de selectieleidraad voor indiening van hun aanvraag tot deelneming, noch in hun antwoord op de vraag om inlichtingen.

De verzoekende partijen lijken voorts in het kader van onderhavige procedure ook uit te gaan van een verkeerde lezing van het keuzerecht tot ondertekening van aanvragen tot deelneming vervat in artikel 42, § 2 van het koninklijk besluit plaatsing 2017. Deze bepaling lijkt kandidaten vooreerst toe te laten om niet over te gaan tot ondertekening van alle afzonderlijke documenten, doch de documenten globaal te ondertekenen via het indieningsrapport dat er betrekking op heeft, net zoals overigens geldt voor offertes conform artikel 42, § 1. Daarnaast blijkt uit deze bepaling en het verslag aan de Koning dat zelfs al is de

ondertekening van de aanvraag tot deelneming op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit plaatsing 2017 zelf facultatief, de ondertekening van het indieningsrapport voor de aanvraag tot deelneming een onmiskenbaar voordeel biedt voor de ondernemer. Immers, indien het eerste UEA niet getekend blijkt of niet geldig getekend blijkt via het indieningsrapport dat samengaat met de aanvraag tot deelneming, moet de ondernemer zijn UEA een tweede maal indienen samen met zijn offerte en haar bijlagen.

Prima facie blijkt echter nergens dat de regelgever met deze bepaling zou hebben beoogd op algemene wijze uit te sluiten dat een aanbestedende overheid dienaangaande strengere verplichtingen zou opnemen in de selectieleidraad.

Er is op het eerste gezicht dan ook geen reden om in te gaan op de vraag van de verzoekende partijen om punt 2.20.5 van de selectieleidraad buiten toepassing te laten met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, indien deze vraag zich op het eerste gezicht al leent tot een beoordeling in het kader van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Overigens lijkt dit ook niet te volstaan nu ook onder punt 3.2 van de selectieleidraad wordt bepaald dat indien de aanvraag tot deelneming wordt ingediend door een samenwerkingsverband de aanvraag tot deelneming door alle leden van het samenwerkingsverband dient te worden ondertekend.

13. Waar de verzoekende partijen nog aanvoeren dat de selectieleidraad geen sanctie bepaalt, lijken zij niet te kunnen worden bijgevalen aangezien de selectieleidraad onder punt “2.14 Uitsluiting van Kandidaten” uitdrukkelijk bepaalt: “Indien de Kandidaten handelen in strijd met de eisen gesteld in de Selectie- en de Gunningsfase, kan dit leiden tot onregelmatigheid van de door de Kandidaten in te dienen documenten en tot uitsluiting van de desbetreffende Kandidaten aan de (verdere) deelname aan deze Plaatsingsprocedure.”

Op het eerste gezicht blijkt in de bestreden beslissing ook toepassing te worden gemaakt van deze bepaling waar wordt gesteld dat “De Aanvraag tot Deelneming van de Kandidaat [...] als niet volledig en formeel

regelmatig [wordt] beoordeeld” en “De Kandidaat wordt uitgesloten van het verder verloop van de plaatsingsprocedure”, en dus niet van artikel 76, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2017.

Nu de selectieleidraad uitdrukkelijk voorzag in de mogelijkheid voor de verwerende partij om te besluiten tot de onregelmatigheid van de door de kandidaten ingediende documenten en tot uitsluiting van verdere deelname aan de plaatsingsprocedure indien de kandidaten handelen in strijd met de eisen gesteld in de selectiefase, waaronder de eis tot geldige ondertekening van de aanvraag tot deelneming lijkt te mogen worden begrepen, was de verwerende partij op het eerste gezicht ook niet verplicht om dienaangaande een regularisatie toe te staan, los van de vraag of dit toelaatbaar zou zijn.

14. Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier en de nota dat de voormelde bepalingen van de selectieleidraad en de bestreden beslissing mede zijn ingegeven door het feit dat de litigieuze opdracht een opdracht betreft in twee fasen waarbij de selectieleidraad voorziet in de mogelijkheid om een doorselectie door te voeren en de selectie te beperken tot slechts vijf kandidaten en een bekommernis tot gelijke behandeling van de kandidaten vanuit dat oogpunt.

De verwerende partij wijst daarbij ook op het belang van het beschikken over een ondertekening van het bij de aanvraag tot deelneming gevoegde UEA bij een dergelijke doorselectie, nu in het omgekeerde geval een risico bestaat dat één of meer gunstig gerangschikte inschrijvers zich in een uitsluitings situatie bevinden.

15. Uit de gemotiveerde selectiebeslissing, die als vertrouwelijk werd neergelegd doch waar de Raad acht op mag slaan, blijkt op het eerste gezicht dat de verwerende partij, ten aanzien van alle kandidaten op de eerste plaats grondig blijkt te hebben onderzocht of de aanvraag tot deelneming voldeed aan de eisen van de selectieleidraad. Wat specifiek de verzoekende partijen betreft, blijkt zij bijkomende informatie te hebben gevraagd inzake de ondertekeningsbevoegdheid en vervolgens ook tot driemaal toe contact te hebben opgenomen met de helpdesk van het e-tendering platform en aldus op zorgvuldige

wijze te hebben onderzocht of er al dan niet sprake kon zijn van een overmachtssituatie in hoofde van de verzoekende partijen.

Uitsluitend onder de aanvragen tot deelneming die voldeden aan de eisen van de selectieleidraad, blijkt de verwerende partij vervolgens ook effectief een doorselectie te hebben uitgevoerd en slechts vijf kandidaten te hebben geselecteerd.

16. In het licht van het voorgaande blijkt op het eerste gezicht dan ook niet dat de verwerende partij zou hebben gehandeld in strijd met de door de verzoekende partijen aangevoerde bepalingen en beginselen door ingevolge de niet geldige ondertekening van de aanvraag tot deelneming en met toepassing van de hoger vermelde bepalingen van de selectieleidraad over te gaan tot uitsluiting van de verzoekende partijen van verdere deelname aan de plaatsingsprocedure.

17. Het enig middel is niet ernstig.

VI. Besluit

18. Het enig middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partijen worden verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 1800 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van zeventien maart tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Johan Bovin,
bijgestaan door
Silja Doms,

staatsraad, waarnemend voorzitter,

griffier.

De griffier

De voorzitter

Silja Doms

Johan Bovin